

1500155-75.2019.8.26.0611

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO

Comarca: Igarapava

Foro: Foro de Igarapava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, ocasião em que foi dada voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Esclareceu que a pessoa que estava dentro da residência, à "meia-porta", não foi abordada e entrou na residência. Contou que CLEBER informou que o dinheiro era dele, fruto do trabalho de vigilante, e que, inclusive, estava indo pra uma festa. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava

Foro de Igarapava

2ª Vara

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, Igarapava-SP - cep 14540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo n. 1500155-75.2019.8.26.0611 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500155-75.2019.8.26.0611

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cleber de Souza da Silva

Tramitação prioritária

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra CLÉBER SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos (fl. 25/26), dando-o como incurso nas sanções previstas pelo artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06.

A prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva (fls. 37/39), devidamente cumprida (fls. 56/58).

A denúncia foi oferecida em 11/07/2019 (fls. 72/74).

Notificado (fls. 97/98), o acusado apresentou defesa prévia (fls. 122/134 e 135/162).

A denúncia foi recebida em 03/12/2019, oportunidade em que afastadas as preliminares e aberta a fase instrutória (fls. 177/178).

A instrução foi realizada, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas de acusação, três testemunhas de defesa e, em seguida, realizado o interrogatório do acusado. Na mesma oportunidade, a prisão preventiva foi revogada (fls. 211/212 e 285/286 - mídias digitais).

Alvará de soltura cumprido (fls. 222/224).

Em sede de incidente de insanidade mental, consta na conclusão "exame médico-psiQUIátrico incompatível com dependência física ou psíquica" (apenso n. 0001922-68.2019.8.26.0242 - fls. 36/38).

O Ministério Público, em memoriais finais, pleiteou o acolhimento parcial da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade delitiva e autoria, requerendo a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 (fls. 290/296).

A Defesa Técnica do acusado, em alegações finais, requereu a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, apontando a insignificância da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de não existir prova de que o réu concorreu para o tráfico de drogas e não existir prova suficiente para condenação pela traficância. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, além de considerar o período em que permaneceu preso para eventual detração penal, bem como a restituição dos bens apreendidos (fls. 300/310).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Preliminarmente, não há qualquer nulidade a ser declarada de ofício. A relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime.

Passo a analisar o mérito.

O réu JOSÉ LUIZ AMBRÓSIO JUNIOR foi denunciado porque, supostamente, no dia 07 de junho de 2019, por volta das 20h00min, na Rua Padre Zeferino, n. 660, Saudade, nesta cidade e comarca de Igarapava/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 13 (treze) porções de cocaína pesando 5,400g (cinco gramas e quatrocentos miligramas). Após regular instrução probatória, a pretensão acusatória merece ser acolhida em parte.

As provas produzidas em juízo não demonstraram com a necessária segurança a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

A testemunha de acusação Fábio de Oliveira Sales, policial militar, em juízo, disse que estava em patrulhamento pela via quando visualizou o veículo na contramão da direção e com a porta aberta, enquanto CLEBER estava fora do veículo no portão da residência, onde havia outra pessoa próxima, e ao avistar a viatura, CLÉBER entrou no carro e tentou engatar a marcha a ré, sendo realizada a abordagem. Contou que, nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal, mas na revista veicular, foram encontradas 13 (treze) porções de cocaína num recipiente plástico no lado do motorista do veículo, além de carteira com R\$ 235,00 em notas e pouco mais de R\$ 7,00 em moedas. Declarou que, questionado, CLEBER alegou ser usuário e que comprou o entorpecente na cidade de Delta/MG em data anterior e disse que o acusado é conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, ocasião em que foi dada voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Esclareceu que a pessoa que estava dentro da residência, à “meia-porta”, não foi abordada e entrou na residência. Contou que CLEBER informou que o dinheiro era dele, fruto do trabalho de vigilante, e que, inclusive, estava indo pra uma festa. Declarou que CLEBER estava lúcido e normal e não resistiu à abordagem (fls. 285/286 – mídia digital). O policial militar Fransérgio Venceslau Teixeira, também arrolado como testemunha de acusação, disse que estava em patrulhamento no local, conhecido por denúncias de tráfico de drogas (Rua Padre Zeferino, n. 660), e o veículo conduzido por CLÉBER estava estacionado na frente do local na contramão e, ao avistar a viatura policial, ele entrou no carro e tentou sair manobrando em marcha ré, momento em que foi abordado. Contou que não foi encontrado nada na busca pessoal, mas na busca veicular, ao lado do banco do motorista, foi encontrado um recipiente plástico com 13 porções de cocaína, razão pela qual foi detido. Declarou que, na carteira do acusado, foram encontrados R\$235,00 em dinheiro, além de R\$ 7,65 em moedas no console central do carro. Declarou que o réu é conhecido dos meios policiais por envolvimento com entorpecentes e havia denúncias contra ele de que promovia a venda de entorpecentes, tanto de usuários quanto de ligações via 190, além de frequentar outros locais, como a Avenida Mogiana e a “Bica”. Disse que CLÉBER alegou que a droga era para consumo próprio, comprou em Delta/MG no dia anterior e pagou R\$

20,00 em cada porção. Esclareceu que não foram encontrados petrechos e o celular do réu foi deixado na Delegacia. Disse que, na frente da residência, mora Givaldo, que também teria envolvimento com drogas, segundo informações, e que estava na calçada quando a polícia se aproximou - esclareceu que Givaldo entrou na residência e, posteriormente, foi feito contato com ele, que informou que não conhecia CLÉBER. Contou que não questionou a origem do dinheiro de CLÉBER e não foi possível constatar se o acusado havia feito uso de alguma substância, além de acrescentar que não resistiu à abordagem. Disse que os familiares chegaram ao local cerca de 30 (trinta) minutos após a apreensão, não sabendo quem informou (fls. 285/286 - mídia digital).

A informante Natália Luciana da Silva, cunhada do réu (irmã da esposa), disse, em juízo, que sua mãe recebeu ligação de um primo noticiando os fatos e, em seguida, ligou para ela ir ao local, o que fez em companhia de Quelcilene e do marido dela. Contou que, à época, CLÉBER morava em Delta e tinha visitado ele no local recentemente, já que iam para lá praticamente todo domingo, e que a mãe de CLÉBER é quem morava na Rua Américo Perani, 336. Declarou que CLÉBER ia trabalhar em Buritizal no dia dos fatos, mas não sabe dizer o que ele foi fazer em Igarapava, tampouco verificou algo referente ao fato em apuração. Esclareceu que, ao chegar no local, CLÉBER estava algemado e deitado no chão e o carro do outro lado. Não soube dizer se CLÉBER tem envolvimento ou foi condenado por tráfico de drogas, apenas que ele estava usando cocaína e pediu conselhos para a família, que recomendou que ele se internasse numa clínica. Acrescentou que CLÉBER já teve um problema com um policial, cujo nome não se recorda, que "folgou" com ele (fls. 285/286 - mídia digital).

A informante Quelcilene da Silva Daniel, tia da esposa do réu, disse, em juízo, que sua irmã, que ficou sabendo dos fatos por outra pessoa, avisou a sobrinha Natália que estava com ela e se deslocaram até o local, onde chegaram cerca de 15 minutos após o ocorrido. Contou que visualizou um policial com uma lata nas mãos. Declarou não saber se o acusado já foi condenado por tráfico de drogas, mas sabe que CLÉBER usava entorpecentes e, inclusive, a família já tinha aconselhado ele. Declarou que ele morava em Delta/MG à época, para onde nunca foi, e tinha pouco contato com ele à época. Contou que CLÉBER trabalhava como segurança (fls. 285/286 - mídia digital).

A testemunha de defesa Reinaldo Ferreira da Silva disse, em juízo, que conhece o réu do trabalho como segurança e que, na noite dos fatos, CLÉBER trabalharia para ele no "Forró da Terceira Idade" em Buritizal/SP, devendo ingressar às 21h00min. Declarou que não presenciou os fatos pois estava trabalhando em Ituverava/SP na Associação Atlética e não soube dos fatos no dia, pois seu celular ficou sem bateria. Disse que CLÉBER e mais um segurança deveriam ir ao local, além de uma mulher de lá mesmo para ficar na portaria e responsável pelos ingressos e de um senhor de lá mesmo terceirizado do clube. Contou que, fora do trabalho, não tem contato com CLÉBER e não sabe de seu envolvimento com tráfico de drogas. Declarou que o conhece há mais de 10 (dez) anos, ele sempre trabalhou bem, nunca deu problemas e sempre foi elogiado no serviço. Disse que nunca o presenciou usando drogas (fls. 285/286 - mídia digital).

O réu CLÉBER SOUZA DA SILVA, por sua vez, em seu interrogatório judicial, disse que possui uma condenação por tráfico de drogas de 2012 e que não deu o depoimento em sede policial. Narrou que estava no local dos fatos para comprar drogas de "Gil" e os policiais, quando da abordagem, queriam que indicasse que a droga pertencia a "Gil" para realizar a busca no interior do imóvel, o que não fez para garantir a integridade física de sua família. Contou que, quando os policiais chegaram e apontaram a arma, estava com o celular na mão com uma porção de cocaína sobre ele e uma nota de R\$ 100,00 enrolada na outra durante a utilização da droga, não sendo possível dar marcha-ré no carro. Disse que foi ao local apenas adquirir a droga e, por isso, o carro estava na contramão: ia pegar e sair, não permaneceria no local. Declarou ser dependente químico e que usava cocaína para permanecer acordado à noite trabalhando como segurança, acrescentando que compraria um litro de leite para "diminuir a adrenalina". Falou deveria estar em Buritizal às 20h50min e ainda iria buscar seu companheiro de trabalho "Hércules", que mora no bairro Waldir,

nesta cidade de Igarapava/SP. Contou que tinha 2 porções de cocaína no bolso esquerdo, cada uma com 3g (três gramas) e pagou R\$ 75,00 em cada, totalizando R\$ 150,00. Declarou que desconhece o recipiente encontrado pelos policiais, que não foi mostrado a ele e foi apresentado apenas na Delegacia. Disse, ainda, que o dinheiro destinava-se ao pagamento da pensão de suas filhas e era originário de benefício previdenciário, pois estava afastado de suas funções principais como gari em Uberlândia/MG. Contou que já teve problemas com o policial militar Fransérgio, sendo registrada ocorrência por abuso de autoridade no mês de fevereiro de 2019 e, inclusive, procurou o Ministério Público neste sentido. Por fim, declarou que o celular apreendido era seu e fora comprado no nome de sua esposa.

Embora tenham sido apreendidos 13 (treze) invólucros de cocaína quando da abordagem do acusado (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudo pericial de fls. 23/24 e 75/76), não ficou cabalmente comprovada qual seria a destinação dada aos entorpecentes, especialmente porque nenhum dos policiais militares que realizou a abordagem visualizou ou indicou movimentos relacionados à traficância pelo réu, valendo apontar que os entorpecentes estariam no carro, enquanto o acusado estava na porta da residência com outra pessoa (suspeita de comercializar drogas), não tendo ainda sido localizados quaisquer objetos relacionados ao tráfico na posse do réu.

Não se ignora que o réu já foi condenado por tráfico de drogas nos autos n. 0091372-68.2012.8.13.0035, por fato ocorrido em 08/07/2012 (fls. 226/227 e 277/278), e nos autos n. 0006059-40.2012.8.26.0242, por fato ocorrido em 16/12/2012 (fls. 279), todavia, não é possível presumir que permaneceu dedicado à atividade delituosa em questão apenas porque encontrado com determinada quantidade de entorpecentes.

Assim, tais circunstâncias, aliadas aos demais elementos dos autos não são capazes de demonstrar, sem sombra de dúvidas, que o acusado praticou o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06. Ou seja, os indícios que autorizaram o recebimento da denúncia não se confirmaram em provas concludentes para a condenação do réu por este delito.

Portanto, diante da fragilidade probatória, da quantidade de droga apreendida (6,420g de cocaína) e, havendo dúvida se os entorpecentes seriam destinados ao narcotráfico, a conclusão deve ser aquela mais favorável ao réu.

Assim sendo, a conduta praticada pelo acusado CLÉBER deve ser desclassificada para o crime previsto no artigo 28 da Lei Federal n. 11.343/2006, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

"Apreendida pequena quantidade de tóxicos e alegando o réu posse da substância proibida apenas para uso próprio, inexistindo prova de tráfico, impõe-se a condenação do acusado tão somente como usuário."

Tal procedimento não acarreta qualquer surpresa à Defesa, motivo pelo qual se torna desnecessária sua intervenção anterior, eis que se encontra baseado em fatos devidamente narrados na peça inicial. Neste sentido, STJ, HC 49416/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. em 01.06.06, DJ de 01.08.06.

Nesse contexto, com o deslinde da instrução, razoável a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de entorpecentes.

Ao contrário do que sustenta a Defesa, é inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta do réu, vez que a pequena quantidade de droga é própria da natureza do delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Nestes termos, ensina Guilherme de Souza Nucci: "Difere este crime do previsto no art. 33, justamente em face da finalidade específica do agente (consumo pessoal). Não se trata de infração de menor potencial ofensivo, mas de ínfimo potencial ofensivo (...) Denominamos de ínfimo potencial ofensivo o crime previsto no art. 28 desta Lei, tendo em vista que, mesmo não sendo possível a transação, ainda que reincidente o agente, com maus antecedentes ou péssima conduta social, jamais será aplicada pena privativa de liberdade".

Nesse sentido:

POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória.

Inviável a aplicação do princípio da insignificância, por ser a posse de entorpecentes para uso crime de perigo abstrato, aliás, a pequena quantidade de estupefaciente é justamente o que a caracteriza, porque a diferencia do tráfico. Condenação mantida. PENA. Estabelecida a reprimenda de prestação de serviços à comunidade, pelo período de dez meses, dada a dupla reincidência do acusado. Manutenção. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1546278-89.2016.8.26.0562; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/06/2019; Data de Registro: 17/06/2019) - grifei.

Apelação Criminal - POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO - Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Oitiva de testemunhas - Conduta típica não alcançada pela bagatela penal. Necessidade de proteção do bem jurídico saúde pública - Inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei de Drogas. Inocorrência. Dispositivo, em tese, constitucional. Questão a ser decidida pela e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral - Reprimenda. Adequação - Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1534108-17.2018.8.26.0562; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022) - grifei. Assim, impõe-se a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 28, da Lei de nº 11.343/06.

Reconhecida, portanto, a ocorrência do delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06 em relação ao réu e a responsabilidade deste, passo à fixação da pena: Na dosimetria da pena, atendendo às circunstâncias do artigo 42, da Lei 11.343/06, bem como do artigo 59, do Código Penal, fixo ao acusado a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, com fundamento no artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/2006. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão acusatória para DESCLASSIFICAR a imputação originária de tráfico para a de posse ilegal de substância entorpecente para consumo pessoal e, desta forma, CONDENAR o acusado CLÉBER SOUZA DA SILVA nas penas do crime do artigo 28, caput, da Lei Federal n. 11.343/06, qual seja, advertência sobre os efeitos das drogas.

A prisão provisória foi revogada e não há fundamentos para sua custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), motivos pelos quais o réu poderá recorrer em liberdade.

Transitada em julgado essa sentença: a) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD) e à Delegacia de Polícia; b) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal;

Expeça-se certidão de honorários à defensora nomeada nos termos do convênio Defensoria Pública/SP e OAB/SP (fls. 118).

Ante a absolvição, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal, defiro a restituição dos valores apreendidos (fls. 09/10) e depositados nos autos (fls. 64) ao réu.

Do mesmo modo, defiro a restituição do aparelho celular Motorola One Vision IMEI 354154103138837 (fls. 09/10), à proprietária Natali Luciana da Silva, conforme nota fiscal acostada aos autos (fls. 144/146).

Ainda, em que pese não constem informações nos autos referentes ao veículo do acusado, conforme solicitado pela Defesa (fls. 305), oficie-se à Delegacia de Polícia para que informe eventual destinação dada ao veículo Corsa, placas KBL-7117 de Delta/MG, bem como eventuais infrações administrativas verificadas quando dos fatos.

Se ainda pendente, determino a destruição dos entorpecentes apreendidos, nos termos do artigo 72 da Lei Federal n. 11.343/06.

Desnecessária a inclusão do nome do condenado no rol dos culpados, tendo-se em vista a revogação do artigo 393 do Código de Processo Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, os benefícios da gratuidade da justiça que neste ato concedo.

Cumpridas todas as formalidades legais, ao arquivo.

Oportunamente, ao arquivo.
Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.
Igarapava, 10 de junho de 2022.

Pedro Henrique Bicalho Carvalho
Juiz de Direito
2ª Vara da Comarca de Igarapava/SP
(assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006)